Sumilla: La pena que le corresponde a un cómplice primario es la misma que le corresponde al autor; entendiéndose que se trata del mismo marco punitivo (pena conminada por el tipo penal). Sin embargo, en cuanto a la pena concreta, tanto el autor como el cómplice pueden recibir distintas penas conforme al particular grado de reproche que les corresponde de forma personal.

Lima, seis de julio de dos mil dieciséis.

I. VISTOS

El recurso de nulidad interpuesto por CARLOS ENRIQUE CANEPA CORNEJO, contra la Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2015, dictada por la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que condenó a CARLOS ENRIQUE CANEPA CORNEJO, como cómplice primario del delito contra la administración pública, en la modalidad colusión, en agravio del Estado, en el extremo que le impuso 4 años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó como reparación civil la suma de S/. 80,000.000 soles, que debe pagar el sentenciado a favor del Estado agraviado.

De conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo penal.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo **CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI**; y,

II. ANTECEDENTES

§ IMPUTACIÓN FISCAL

El representante del Ministerio Público, en la Acusación escrita de folios 2774 al 2787, imputa al acusado Carlos Cánepa Cornejo, hechos punibles ocurridos durante el año 1998; en circunstancias que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Carlos Acho Mego, suscribió con la empresa Servicios Logísticos CLASS, representada por el recurrente; cinco contratos diferentes de locación de servicios, un primer contrato N.° 008-98, de fecha 6 de febrero de 1998; el segundo contrato N.° 025-1998, de fecha 06 de febrero de 1998; el tercer contrato N.° 118-

1998, de fecha 13 de junio de 1998; el cuarto contrato N.° 119-98, de fecha 03 de junio de 1998; y, el quinto contrato N.° 120-1998; en mérito a los cuales, la empresa Logística CLASS ponía a disposición de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Personal Técnico profesional a efectos de que prestara servicios en las diferentes oficinas del Programa Nacional de Inversiones PROMI de dicha Comuna. Este personal, aparentemente, habría sido puesto a disposición de la Municipalidad, de acuerdo a las necesidades de recursos humanos; lo que conllevó a que la Municipalidad efectuara diversos desembolsos de dinero a favor de dicha empresa, cuyo monto asciende a S/. 1479,700.42; desembolsos que se acreditan con 26 comprobantes de pago, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 1998; el último de los comprobantes data del 15 de julio de 1998. Sin embargo, la Contraloría General de la República, evidenció entre otras irregularidades, que la contratación de este servicio no se efectuó de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, pues se omitió convocar a los procesos de selección establecidos por ley, ya sea una adjudicación directa, por concurso público de precios o una licitación pública, ya que, revisados los archivos de la Municipalidad, no se encontró ningún documento que diera cuenta de la forma en que se efectuó la contratación, ni mucho menos se apreciaron archivos que justificaran la necesidad de contratar estos servicios y de suscribir estos contratos; tampoco se encontró documento alguno que respalde que, efectivamente, la empresa del referido acusado prestó servicios a la Municipalidad; es más, había una relación de trabajadores que supuestamente prestaron servicios a la entidad, sin embargo, no todas las planillas de la empresa contaban con las firmas que acreditaran que los trabajadores cobraron las remuneraciones que les correspondía, por la prestación de los servicios; tampoco existía documentación que sustente los informes que hubiera realizado la empresa Servicios Logísticos CLASS; de este modo, se habrían efectuado pagos a esta empresa sin acreditarse si realmente los servicios que ésta ofreció se cumplieron, es más, los comprobantes de pago apuntaban listados de trabajadores, pero estos listados no guardaban correspondencia con las

planillas de pago. Por lo que se entiende que la empresa cuya representación ostenta el procesado, Carlos Enrique Cánepa Cornejo, habría concertado acuerdos y plasmado contratos manifiestamente ilegales y sin sustento alguno con el ex Alcalde de la Municipalidad de Coronel Portillo, Carlos Acho Mego y algunos ex funcionarios de esa gestión, con la finalidad de beneficiarse económicamente de los fondos de dicha entidad.

§ SENTENCIA IMPUGNADA

En el extremo recurrido (la pena), la Sentencia cuestionada señala que las modificaciones a los artículos 45°, 46° y la introducción del artículo 45°-A, sobre determinación e individualización de la pena, de la Ley N.° 30077, no resultan aplicables al presente caso, pues los hechos ocurrieron con anterioridad; indica además, que al existir una sentencia condenatoria anterior, la aplicación de criterios distintos para la determinación de la pena, vulneraría el principio de igualdad ante la ley, por lo que debe aplicarse los criterios adoptados con anterioridad. Sobre esa base, el Colegiado Superior tuvo en cuenta la naturaleza de la acción –actuando el condenado como *extraneus*-, la importancia de los deberes infringidos –se coludió con el Alcalde para defraudar al Estado-, el grado de instrucción y ocupación del procesado –instrucción superior, asistente de contador-, los antecedentes –cuenta con antecedentes penales- y la conclusión anticipada. Agrega, que la pena privativa de libertad debe ser efectiva, pues, de lo contrario se generaría sensación de impunidad ya que "justamente en aquellos casos de corrupción, que son materia del proceso penal, se dictan sentencias condenatorias, que generalmente, su ejecución se suspende".

III. CONSIDERACIONES

§ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DEL RECURSO

1. En el presente caso, la Sala Superior Penal no ha notificado la Sentencia al momento del acto de lectura de sentencia, incumpliendo la Sentencia Plenaria N.° 01-2013/301-A-2-ACPP, en la que, en el fundamento décimo, textualmente se señala que "(...)

como quiera que lo notificado o leído son autos o sentencias - no proyectos o documentos sin firma-, **corresponde al órgano jurisdiccional la obligación de entregar a todas las partes, acabada la audiencia o el acto de lectura del auto o sentencia, la resolución correspondiente, lo que debe constar en el acta, bajo responsabilidad**".

2. Sin embargo, esta irregularidad en la notificación de la Sentencia, no puede perjudicar al recurrente por cuanto tendría que anularse la sentencia y disponerse nuevo juicio oral, afectándose el derecho fundamental del imputado de ser juzgado en un plazo razonable; por lo que, en aplicación del principio de economía procesal, este Supremo Tribunal, se pronunciará sobre el fondo del recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Canepa Cornejo.

§ AGRAVIOS QUE EXPONE EL IMPUGNANTE

3. El recurrente Carlos Enrique Canepa Cornejo, fundamenta su recurso de nulidad a folios 3256 al 3263, señalando lo siguiente:
   a. Para determinar la pena se debió considerar que actuó como *extraneus* y no como funcionario público. Asimismo, los funcionarios públicos que han sido condenados, han sido sentenciados a pena privativa de libertad de 3 años, cuya ejecución se ha suspendido, por ello, a él le correspondería la misma pena, de conformidad con el artículo 25° del Código Penal ("El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor").
   b. El criterio de la Sala, al no aplicar el artículo 25° del Código Penal, no se encuentra motivado así como está vulnerando el derecho a la defensa.
   c. Agrega, que la Sala Superior se ha equivocado al consignar y valorar que tiene antecedentes penales cuando en rigor no los tiene.
   d. La reparación civil no está motivada.

§ ARGUMENTOS DE LA SALA SUPREMA EN CUANTO A LA PENA

4. La determinación de la pena no es ni ha sido –antes de las modificaciones introducidas por la Ley N.° 30077- un procedimiento subjetivo y librado a la intuición, comprensión o leal saber y entender del juez, es, por el contrario, un procedimiento racional y que se rige por la actuación conjunta de varios principios y reglas, entre las primeras, la legalidad de las penas y la motivación de las resoluciones judiciales. Por ello, debe sostenerse que el sistema de determinación e individualización de la pena de forma estructurada, no existe solo luego de las reformas introducidas por las Leyes N° 30076 y N° 30077, sino que subyacía en sus elementos directrices con anterioridad a dichas modificaciones; estando desarrolladas en el Acuerdo Plenario N.° 1-2008/CJ-116, así como en el Acuerdo Plenario N.° 8-2008/CJ-116, Acuerdo Plenario N.° 2-2010/CJ-116, Sentencia de la Sala Penal Especial en el Exp. N.° A.V. 19-2001 y el R.N. N.° 19-2009 A.V.

5. Asimismo, esta labor de determinación e individualización de la pena no es ajena a los casos de Conclusión Anticipada del juicio oral, por el contrario, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 16° del Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, en la conclusión anticipada el "Tribunal (...) tiene una amplia libertad, dentro del marco jurídico del tipo legal en cuestión [pena abstracta], para dosificarla conforme a las reglas establecidas por los artículo 45° y 46° del Código Penal, cuyo único límite, aparte de no introducir hechos no incluidos en la acusación ni aceptados por el imputado y su defensa, es no imponer una pena superior a la pedida por el Fiscal –explicable por la propia ausencia de un juicio contradictorio y la imposibilidad de formularse, por el Fiscal o de oficio, planteamientos que deriven en una pena mayor a la instada en la acusación escrita-".

6. Bajo estos parámetros, en cuanto al agravio del recurrente, conforme al cual es *extraneus* y por tanto debió imponérsele la misma pena que los autores, de conformidad con el artículo 25° del Código Penal;

esta Sala Suprema debe desestimar este argumento en base a dos consideraciones. Por un lado, el derecho penal moderno observa y respeta el principio de culpabilidad, conforme al cual la responsabilidad es por el hecho propio y no de un tercero o únicamente por el resultado, por ello, está proscrita la responsabilidad objetiva. Siendo esto así, la pena asignada es individual, pues, se verifica en cada caso concreto el nivel o grado de reproche de la conducta, siendo total y válidamente posible imponer distintas magnitudes de pena a coautores o autores y cómplices primarios. Por otro lado, cuando el artículo 25° del Código Penal, prevé que: «El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, **será reprimido con la pena prevista para el autor**»; debe interpretarse en el sentido de que a la persona que "presta auxilio en la comisión del delito" **le es aplicable el mismo marco punitivo (pena abstracta o básica) que le corresponde al autor, sin embargo, a cada uno debe individualizársele la pena conforme al particular grado de reproche que les corresponde de forma personal.** En otros términos, el mencionado artículo no debe ser entendido en el sentido de que la pena concreta que se le impone al autor, debe imponerse al participe, o cómplice. Sostener ello vulneraría el principio de culpabilidad, pues, el grado de reproche siempre estaría en función al autor, asignándole el mismo nivel -de forma objetiva- a los cómplices, lo que resultaría irracional.

7. Con relación al agravio de carecer de antecedentes penales; se observa de folios 3139 que el recurrente sí tiene antecedentes penales, por lo que el factor genérico de agravación de la pena, utilizado por la Sala Penal sentenciadora, si está presente y fue debidamente incorporado al razonamiento judicial.

8. En buena cuenta, en cuanto a la determinación e individualización de la pena, verificando que el impugnante ha sido sentenciado como *extraneus* del delito contra la administración pública, en la

modalidad de colusión, y que en el caso concreto sólo concurren circunstancias de agravación genérica, de lo que debe restarse el beneficio premial de conclusión anticipada; la pena debió ser fijada en 6 años de pena privativa de libertad. Por ello, la pena así como su efectividad, fijada por la Sala Sentenciadora, al ser inferior a la que individualiza este Supremo Tribunal, debe ser mantenida en virtud del principio de non *reformatio in peius* (no puede empeorarse la situación del impugnante, cuando no hay impugnación del Ministerio Público).

§ ARGUMENTOS DE LA SALA SUPREMA EN CUANTO A LA REPARACIÓN CIVIL

9. En cuanto a la reparación civil, se verifica que la Sala Superior ha justificado el *quantum* de la misma, considerando además la Sentencia recaída en el Exp. N.° 2000-289-242501-JP02, caso conexo con el presente proceso, en el que se habría determinado una reparación civil de S/. 1,000.000.00 de soles. Sobre este extremo, esta Sala Suprema no comparte el monto de la reparación fijado por el Colegiado Superior, pues, no ha considerado que el artículo 93° del Código Penal prevé que la reparación civil incluye la "restitución del bien", el cual es muy superior al impuesto en la sentencia, asimismo, no ha considerado la reparación civil fijada en la Sentencia recaída en el ya mencionado expediente, que no es sólo por este acto sino por otros hechos delictivos. Empero, nuevamente, en virtud del principio de non *reformatio in peius*, este Tribunal debe mantener el monto fijado en este extremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

1. **NO HABER NULIDAD** en la Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2015, dictada por la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que condenó a CARLOS ENRIQUE CANEPA CORNEJO, como cómplice primario del delito contra la administración pública, en la modalidad colusión, en agravio del Estado, a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó como reparación civil la suma de S/. 80,000.000 soles,

que debe pagar el sentenciado a favor del Estado agraviado; con lo demás que contiene, y que es materia del recurso, y los devolvieron.

2. **EXHORTAR** a los señores Jueces Superiores, Martínez Castro, Guzmán Crespo y Dueñas Alvarado, poner mayor celo en el desempeño de sus funciones, por la irregularidad observada en los fundamentos 1 y 2 de la presente resolución.

S.S.

VILLA STEIN

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

HINOSTROZA PARIACHI

NEYRA FLORES

HP/JCSC.

20 OCT 2016

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA